

1500575-25.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500575-25.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500575-25.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA SANTOS ADDEO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GABRIELA SANTOS ADDEO foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a Denúncia (fls. 83/85) que, no dia 07 de março de 2021, em torno das 09h20 min, na Rua da Estação, na via pública, altura do nº 355, Centro, nesta cidade e Comarca de Osasco, GABRIELA SANTOS ADDEO, qualificada a fls. 11, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína na forma de "crack", no total de 9,30g (nove gramas e trinta centigramas) e 16 (dezesesseis) porções de Cannabis sativa L (maconha), no total de 29g (vinte e nove gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08/09, laudo de constatação de fls. 17/20, fotografias de fls. 24, 25 e 26 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

Narra, ainda, a inicial acusatória que, segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos quando, no sítio em questão, avistaram a denunciada em atitude que julgaram suspeita, tendo em vista ela estar parada na passarela ali existente, obstruindo a passagem e o fluxo de pessoas, a denunciada,

ao perceber que seria abordada, tentou evadir-se, em vão posto ter sido alcançada e detida. Durante a breve fuga, a denunciada dispensou, ao solo, uma sacola plástica que, ao ser recuperada, constatou-se conter porções de maconha e "crack".

Em revista pessoal, os milicianos ainda localizaram, em poder da denunciada, a quantia de R\$ 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos), fruto da mercancia espúria de entorpecentes. Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a tentativa de fuga e a presença de dinheiro de origem lícita não demonstrada, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de exibição e apreensão às fls. 15.

Laudo pericial toxicológico de constatação às fls. 17/20. Laudo pericial toxicológico definitivo às fls. 92/94.

Fotografias dos entorpecentes apreendidos às fls. 24/26.

A prisão em flagrante da acusada (fls. 01/02 e 06/07) foi homologada, sendo concedida à denunciada liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 53/57). A audiência de custódia foi dispensada, em caráter excepcional, em razão do Covid-19. Alvará de Soltura cumprido às fls. 116/119.

A notificação da acusada foi determinada em decisão de fls. 86.

Em primeiro momento a denunciada não foi encontrada em sua residência para receber a notificação pessoal (fls. 95), posteriormente foram feitas novas tentativas infrutíferas para localizar a ré, tendo sido esgotados os meios disponíveis nos autos para sua notificação (fls. 126).

Em decisão de fls. 130/136, procedeu-se à conversão do rito especial previsto na Lei 11.343/06 para o rito ordinário do Código de Processo Penal; a denúncia foi integralmente recebida e foi determinada a citação por edital da acusada.

Não comparecendo a ré no processo após citação editalícia, nem tendo sido citada pessoalmente, os autos foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP (fls. 157/159).

Citada (fls. 194/195), a denunciada apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, às fls. 199/200.

Em decisão de fls. 202/204, este juízo: (i) revogou a suspensão decretada em decisão de fls. 157/159, retomando o andamento do processo e do curso do prazo prescricional; (ii) manteve o recebimento da denúncia e (iii) designou audiência de instrução, debates e julgamento PRESENCIAL para o dia 04.08.2022, às 10h00.

Ocorre que a audiência ora designada se deu por prejudicada, pela ausência de intimação da ré (fls. 224/226). Assim, foi redesignada para o dia 22.09.2022, às 10h00.

Folha de antecedentes às fls. 219/221.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação. Foi decretada a revelia da acusada.

Em debates a Acusação pede a condenação nos termos da inicial.

Em debates, por sua vez, a Defesa sustentou a absolvição, sustentando ausência de

motivos para a abordagem pessoal eis que não flagrada atitude típica de tráfico. Não era possível verificar se na sacola havia drogas. Aduz que seria possível a ré jogar a sacola por cima da passarela ou na linha de term. Não havia outra pessoa, e não foi vista interagindo com outras pessoas o que legitimasse a abordagem policial. Também não foi apontada a destinação do entorpecente, pois mera suposição. Não há provas que ela estaria traficando. Há possibilidade dela ser usuária. Em caso de condenação, pena base, redutor no máximo, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É relatório.

Fundamento e decido

A - Preliminarmente, anoto que não se verifica ilegalidade na conduta dos policiais a ponto de tornar a prova ilícita. A abordagem policial não foi tão somente baseada em "tirocínio" dos agentes públicos ou somente em "nervosismo", o que denotaria o mais puro subjetivismo, mas sim em comportamento efetivo, vale dizer, porque a ré, ao descer a passarela, com algo nas mãos, avistou a viatura e, por esta razão, voltou a subir a passarela de modo rápido, tendo, no trajeto de subida, dispensado uma sacola a qual, segundo os policiais, foram vista em suas mãos. Assim, cumprido o standard do art. 244 do CPP para atuação policial.

B - Do mérito

B.1 - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 92/94) e fotografia (fls. 24/26).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório da ré em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"), eis que a ré, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, ainda que pequena, trazia entorpecentes destinado a terceiras pessoas.

A ré não foi ouvida em juízo posto que revel. Desta sanção processual não é possível a extração de qualquer consequência jurídica.

Por outro lado, em que pese a ausência de versão da ré, as provas produzidas em juízo pelo Ministério Público, corroboradas pelos elementos materiais (laudo e fotografias), permitem a superação da presunção constitucional para além de qualquer dúvida razoável.

O policial Lindailso relatou que, em patrulhamento com seu parceiro, ambos avistaram a ré Gabriela na passarela. A passarela estava em um lado demolida e em outro havia acesso. Viram a acusada descer com uma sacola. Ao descer, ela jogou a sacola. Seu parceiro realizou a abordagem. A ré correu para o outro lado. Seu

parceiro foi para o outro lado para abordar a acusada. Foi ver o que ela tinha dispensado. Tratava-se de uma sacola com o entorpecente (Maconha e crack), fracionado. Foram apreendidos R\$ 67,00. O local é um ponto de tráfico. A ré estava na escada. Patrulhava na via e estava a 5 metros mais ou menos da acusada. A ré subiu a escada para descer pelo outro lado. Neste momento largou a sacola plástica. O dinheiro estava nas vestes, o qual foi entregue.

O policial Vagner, por sua vez, relatou que, em patrulhamento de viatura, junto com seu parceiro, observaram que uma mulher descia a escada da passarela. Quando viu a viatura ela correu, subindo novamente as escadas. Desembarcou rápido e foi atrás da mulher que dispensou uma sacola. Foi abordada. Foi perguntado o que tinha jogado. No momento se recusou a fala. Foi localizado entorpecente. A ré disse que era usuária. Outras viaturas chegaram e ela foi conduzida ao Distrito Policial. Somente havia a ré na passarela pois esta estava quebrada e não apta ao trânsito de pessoas. Foram apreendidos 16 papelotes de "maconha", 67 de "crack" e R\$ 67,00 em dinheiro. Presenciou o momento no qual a acusada teria dispensado a droga no chão. A distância era 1 a 2 metros. A ré estava acessando a rua no momento que foi visualizada. Quanto a passarela, metade estava inoperante. A prefeitura tampou o acesso total tendo em conta que alguns usuários utilizavam o local para consumo de drogas. Em relação a passarela, não havia como passar para o outro lado, somente se a pessoa pulasse ou descesse por uma corda. A noite o consumo de droga era constante no local. Sempre tem algum usuário no local diante da pouca visibilidade. Não foi indagado se ela permaneceu no período da noite usando drogas. Quando a ré estava quase para acessar a rua viu a viatura, olhou e apresentou nervosismo. A sacola caiu na escada.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais.

Com efeito, os policiais, em resumo, e essencialmente, afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram a ré descendo a escada da passarela, a qual, por estar em obras, estava interditada e não permitia acesso ao outro lado. A ré, quase acessando a rua, avistou os policiais e, neste momento, de inopino e de forma rápida, voltou a subir a passarela. Enquanto descia, os policiais viram que trazia algo nas mãos. Ao subir, dispensou a sacola. No seu interior havia as drogas descritas na inicial. A ré estava sozinha no local. Além das drogas, foi apreendida uma quantia em dinheiro que foi entregue aos policiais.

Portanto, a premissa fática do Ministério Público, qual seja, que no dia 07 de março de 2021, em torno das 09h20 min, na Rua da Estação, na via pública, altura do nº 355, Centro, nesta cidade e Comarca de Osasco, GABRIELA SANTOS ADDEO, qualificada a fls. 11, trazia consigo (...), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína na forma de "crack", no total de 9,30g (nove gramas e trinta centigramas) e 16 (dezesesseis) porções de Cannabis sativa L (maconha), no total de 29g (vinte e nove gramas) está devidamente comprovada nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de trazer consigo entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e

que as drogas seriam para consumo de terceiros, tendo em vista a forma como acondicionadas, a quantidade e as condições nas quais se desenvolveu a ação (a ré ao ver os policiais empreendeu fuga subindo as escadas). Não há dúvidas, portanto, que a droga estava com a ré - em uma sacola - e se destinava ao comércio espúrio. Em que pese haver pequenas divergências nos depoimentos e o fato da ré não ter interagido com outras pessoas para venda de drogas, estes pontos não são capazes de infirmar a prova produzida e afastar a responsabilidade penal.

B.2 - Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal e ser portador de bons antecedentes (sem condenação não apta a gerar reincidência) - fls. 26. Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, não há qualquer elemento que demonstre que o réu se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: AGRADO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRADO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele "não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas". II - Agrado regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer à organização criminosa. Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta, qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: "§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela. Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

No caso dos autos, não há qualquer mínimo elemento que demonstre de forma pressuposta envolvimento com organização criminosa.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a quantidade de drogas é não significativa e, ainda, a réu é primária e não ostenta antecedentes (fls. 87).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias multa.

A ré preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mais multa.

A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

Somando-se as multas chega-se ao total de 177 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas da ré.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:
CONDENO GABRIELA SANTOS ADDEO, qualificada nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 177 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração aos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

E - Demais deliberações

Pela natureza da sanção o réu poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Determino a destruição dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e

Realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 22 de setembro de 2022.